

0000198-51.2022.8.26.0136

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

1ª Vara

Rua Olímpio Pavan, 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000198-51.2022.8.26.0136 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000198-51.2022.8.26.0136

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - AH8072-2/2022 - Delegacia de Polícia de Iaras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS GABRIEL BERTOLANI DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

NICOLAS GABRIEL BERTOLANI DE ARAUJO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 09 de fevereiro de 2002, por volta das 06h13min, na casa localizada na Rua Francisca A. Berenger, 382, São Benedito, Iaras, nesta Comarca de Cerqueira César/SP, guardava em sua residência, para fins de tráfico, 23 (vinte e três) porções de maconha, 1 porção de maconha com 2,1g, além de uma porção de cocaína e uma porção de crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de exame preliminar a fls. 33/43 e auto de exibição e apreensão de fls. 18/20.

Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/52. Por decisão proferida em 10 de fevereiro de 2022, a prisão em flagrante foi convertida

em prisão preventiva (fls. 69/73). Mandado de prisão cumprido a fls.80/81. A denúncia foi oferecida em 20 de fevereiro de 2022 e o réu, notificado a fls.133 , ofereceu Defesa Prévia a fls. 109/110. Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 05 de abril de 2022, oportunidade na qual também foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 134/135). Em audiência, foram inquiridas 02 testemunhas de acusação e o réu interrogado (gravações audiovisuais). Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (fls.201/208). A douda Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, subsidiariamente, em caso de condenação, pela aplicação do parágrafo 4º, do art. 33 da lei de drogas , bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime aberto e poder recorrer em liberdade (fls. 194/199).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "o acusado teve as porções de maconha que guardava localizadas em sua residência durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo de Santa Cruz do Rio Pardo.Ao chegarem no local, os policiais constataram que NICOLAS não estava na residência, porém, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, no quarto do denunciado foram encontradas,dentro de uma caixa de celular, as porções de maconha, envoltas em um saco plástico, com uma etiqueta de papel com desenho de um homem de óculos e uma folha de maconha.Ainda no local, foram encontradas outras 24 etiquetas com o mesmo desenho do homem de óculos e uma folha de maconha.Policiais prosseguiram nas buscas para localizar NICOLAS, sendo que durante a tarde, foi ele encontrado, retornando de uma consulta médica. Com ele foi encontrada uma pedra de crack, uma porção de maconha com a mesma etiqueta das drogas achadas em sua casa e uma porção de cocaína.

No mérito, à luz da prova produzida, a denúncia procede integralmente.

A materialidade delitiva restou configurada pelo auto de prisão em flagrante a fls. 01, boletim de ocorrência a fls. 07/10, auto de exibição e apreensão a fls. 18/20, laudo de constatação provisória a fls. 33/43, laudo toxicológico a fls. **, bem como por toda a prova oral produzida em juízo.

A autoria delitiva, de igual modo, também restou inconteste e recai sobre o réu.

A testemunha de acusação Diego do Amaral , policial civil, disse que foi acionado para dar apoio operacional ao cumprimento de um mandado de busca e apreensões domiciliares e de mandados prisões temporárias, na cidade de Iaras, referente aos processos nº 1500094-37.2022.8.26.0539, da Vara Criminal de Santa Cruz do Rio Pardo, os quais se referiam a roubos em praças de Pedágio. Dirigiram-se até a casa do acusado, acompanhados de um cão farejador, entretanto, Nicolas não se encontrava na casa. No interior da residência encontraram diversas porções de drogas, as quais estavam embaladas com uma etiqueta personalizada, constando ainda o valor de cada porção. Além disso, havia várias etiquetas iguais as supra mencionadas, dentro de seus pertences. Diligenciaram a fim de conseguir informações acerca do paradeiro do réu, que teria ido até São Paulo para realizar um consulta médica. Localizaram Nicolas na Rodovia Castelo Branco SP 280, por volta de 15h30min, e realizaram a abordagem no veículo da Secretaria Municipal, no qual estavam Nicolas e sua mãe e um funcionário da Prefeitura. Cientificaram Nicolas do mandado de prisão, bem como do encontro de diversas porções de droga em sua casa, todas fracionadas, embaladas e prontas para venda, etiquetadas constando o valor de cada porção. Em busca pessoal, localizaram em sua posse , uma porção aparentando ser cocaína embalada e uma porção de crack, e uma porção de maconha, a qual estava embalada com a mesma etiqueta encontrada nas porções localizadas em sua casa."

A testemunha de acusação Edson Barca, policial civil, judicialmente, "corroborou a versão de seu colega policial. Acrescentou que na casa de Nicolas foram comunicados acerca da localização de 23 (vinte e três) porções de maconha, dentro de uma caixinha de celular, embaladas com uma etiqueta personalizada. Além das etiquetas que estavam nas embalagens , existiam mais etiquetas junto da mesma caixinha de celular."

A informante Rosenilda de Fátima Bertolani Gomes, mãe do acusado, "disse que no

dia dos fatos, ficaram sabendo do cumprimento do mandado de busca e apreensão quando estavam em São Paulo. Tendo em vista que Nicolas foi a um retorno médico, pois iria fazer uma cirurgia no ombro. Resolveram que passariam no médico e após retornariam para Iaras, para que ele se entregasse. Relatou que seu filho não é traficante. Nunca encontrou drogas em seu quarto. Afirmou que Nicolas é usuário de drogas, porque costumava encontrar embalagens vazias em seu quarto e também tinha odor de drogas. Disse que queria internar seu filho, entretanto, este negava ser usuário de drogas.

O réu Nicolas Gabriel Bertolani de Araujo, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitativa. Disse que os entorpecentes encontrados em sua residência destinavam-se a consumo próprio, uma vez que é usuário de drogas e está passando dificuldades na vida. Negou que esteja traficando drogas. Relatou que quando estava em São Paulo, ficou sabendo do mandado de busca e apreensão e resolveu se entregar, indo ao encontro dos policiais. "

Com efeito, a negativa de autoria do réu nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais, além da prova da materialidade.

Nesse contexto, a versão do acusado além de inconsistente e implausível de per si, permaneceu de todo isolada no contexto probatório, já que ele nada produziu, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação, não havendo, pois, qualquer razão para desacreditá-los. Nesse sentido: "... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.). Assim, as provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pelo réu. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se das circunstâncias da prisão, da quantidade e diversidade de drogas apreendidas 23 (vinte e três) porções de maconha, 1 porção de maconha com 2,1g, além de uma porção de cocaína e uma porção de crack), do modo pelo qual estavam acondicionadas, inclusive com etiquetas que continham até o valor da porção.

Outrossim, os depoimentos prestados pelas testemunhas, da fase inquisitiva à judicial, foram firmes e seguros, não se vislumbrando qualquer interesse em acusar ou prejudicar o réu, merecendo plena credibilidade a versão por eles ofertada. Não se pode conceber a justificativa rasa de que os policiais permanecem perseguindo cidadãos e atribuindo-lhes a propriedade de quantia tão grande de entorpecente com o único fim de prejudicar o réu. Nesse sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846) (g.n.).

De mais a mais, ressalto que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras

de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

De outra feita, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que o réu praticava o comércio de entorpecente, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu NICOLAS GABRIEL BERTOLANI DE ARAÚJO, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos elementos preconizados pelo artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (F.A. e certidões a fls.53/56), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, não há causas de aumento. Por outro lado, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa ou de que esteja presente a habitualidade delitiva. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO, 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA , COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020).

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qual-

quer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55 do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, REVOGO a prisão preventiva decretada a fls. 63/66, podendo o réu recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República, oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu, e providencie-se o necessário para o cumprimento da sanção penal imposta. Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias e efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Cerqueira Cesar, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA